

1500360-83.2021.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... se o réu possuía envolvimento com tráfico de drogas. Não ouviu, em nenhum momento, os policiais dizendo que era denúncia de tráfico de drogas. Conhece o réu desde quando ele era criança e tem conhecimento de que ele trabalhava como motoboy para sua cunhada. Afirmou que sua residência fica na mesma calçada que a de Gabriel, já que, em frente, há um campo de futebol, uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500360-83.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500360-83.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2101237/2021 -

DEL.POL.ITAPIRA, 12036466 - DEL.POL.ITAPIRA, 1304/21/930 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FERNANDO PINHEIRO BARREIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou GABRIEL FERNANDO PINHEIRO BARREIRO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 11 de abril de 2021, por volta das 13h30, na Rua José Pelizer, nº 183, Conjunto Habitacional Vila Penha do Rio do Peixe, nesta cidade e Comarca de Itapira, o acusado tinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, 30 (trinta) microtubos de cocaína, pesando aproximadamente 57g (cinquenta e sete gramas), 157 (cento e cinquenta e sete) pedras de crack, substância derivada da cocaína, pesando aproximadamente 43g (quarenta e três gramas), e 01 (uma) porção Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 270g (duzentos e setenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13.

Segundo a inicial, policiais militares, após denúncia anônima de que no local dos fatos seria recebido um carregamento de drogas, deslocaram para ali, onde se depararam com Silvia Helena Pinheiro, genitora do acusado. Ato contínuo, com a

autorização de Silvia, os agentes da lei adentraram na residência, oportunidade em que, na cozinha, foi encontrada a porção de maconha, além de embalagens comumente utilizadas para embalo de drogas e apetrechos. Posteriormente, indagaram-na sobre a propriedade das drogas, ocasião em que Silvia afirmou pertencer ao seu filho, ora acusado, conduzindo os policiais militares até o quarto de GABRIEL, local em que foram encontradas 157 (cento e cinquenta sete) pedras de crack, 30 (trinta) microtubos de cocaína, além do valor em dinheiro de R\$ 3.191,00 (três mil, cento e noventa e um reais).

Laudos periciais toxicológicos às fls. 35/43.

O acusado foi notificado (fls. 58) e ofereceu defesa prévia (fls. 60/74).

A denúncia foi recebida aos 14 de setembro de 2021 (fls. 81/84).

Citação do acusado às fls. 104.

Em audiência (fls. 137/138), foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia, três testemunhas de defesa e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais orais.

A Representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A Defesa, em sede preliminar, requereu o reconhecimento de ilicitude das provas por usurpação da competência da polícia judiciária e por violação de domicílio; bem como violação do princípio da ampla defesa e do contraditório diante da ausência de registro da denúncia anônima. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a aplicação da pena mínima, aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

Inicialmente, observo que as questões trazidas preliminarmente pela defesa não passam de repetição do quanto já alegado em sede de resposta à acusação e, portanto, já foram apreciadas na decisão de fls. 81/84.

Todavia, reitero os fundamentos nela expostos.

De acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, as autoridades policiais e seus agentes, assim como qualquer pessoa do povo, estão legitimados a intervir, valendo-se de meios proporcionais e moderados, a fim de obstar qualquer prática criminosa em andamento, podendo, até mesmo, dar voz de prisão em flagrante.

No caso em apreço, os policiais militares receberam denúncia anônima sobre a chegada de um carregamento de droga na casa do acusado, já conhecido nos meios policiais. Uma vez ali, a genitora do acusado, que estava na frente da residência, foi informada sobre a situação e autorizou a entrada dos agentes no imóvel, onde foram encontrados dinheiro, drogas e objetos próprios para preparo e armazenamento de entorpecente.

Nesse cenário (denúncia específica e encontro de grande quantidade de entorpecente), nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, havia fundadas suspeitas contra o acusado.

A partir de então, os policiais levaram o ocorrido ao conhecimento da polícia judiciária, que passou a conduzir regularmente a investigação, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Com relação à alegada violação de domicílio, imperioso destacar que o delito de tráfico de drogas é crime permanente e, portanto, independe da existência de autorização judicial.

Nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, sendo exatamente esta a exceção prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que trata da violação ao asilo quando há situação de flagrante.

Confira-se:

"A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". (negritei)

No caso, o réu mantinha expressiva quantidade de entorpecente no local, além de grande quantia de dinheiro e petrechos utilizados na traficância ilícita, existindo, assim, a situação de flagrante delito, a qual é apta, por si só, a autorizar a entrada dos policiais no imóvel, independentemente de qualquer autorização ou mandado judicial.

Nesse sentido:

"Com efeito, cumpre esclarecer que é desnecessário mandado de busca e apreensão quando o agente se encontra em estado de flagrância, mormente em razão do que preceitua o artigo 5º, incisos XI e LXI, da Constituição Federal, nos quais se encontram permissivos excepcionais de violação do domicílio e de restrição da liberdade do indivíduo em razão de flagrante delito. E há que se ter presente que o paciente foi acusado da prática de crimes de natureza permanente, quais sejam, tráfico de entorpecentes na modalidade "[...] ter em depósito, [...] ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar "; e receptação na modalidade "ocultar, em proveito próprio [...] coisa que sabe ser produto de crime". (...) Desse modo, extrai-se das passagens acima que é dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se trata de flagrante delito, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio". (STJ, HC 188.195/DF, 5ª Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. 27.09.2011)

Portanto, o estado de flagrância autoriza que os agentes ingressem em qualquer local para efetuar a prisão.

Rejeito, portanto, as matérias preliminares.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 06/08, no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e nos laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 35/43, os quais apontaram o caráter entorpecente das drogas apreendidas, conhecidas por cocaína e maconha, capazes de gerar dependência física e psíquica a quem delas faz uso, além da prova oral produzida.

A autoria é certa.

Vejamos.

A testemunha Silvia Helena Pinheiro disse ser mãe do acusado. Não soube dizer se ele estava traficando no dia dos fatos. Por ocasião do ocorrido, estava sentada no banco existente em frente à sua casa, quando policiais lá chegaram e lhe disseram que havia uma denúncia de maus tratos a um idoso. Na época, só havia sua mãe idosa na casa, que veio a falecer um mês depois. Diante da insistência dos policiais, sua filha, que residia ao lado, de prenome Mariele, autorizou o ingresso dos policiais na residência e os acompanhou, ocasião em que foi encontrada grande quantidade de drogas, ou seja, 30 pinos de cocaína, 150 pedras de crack e 270 gramas de maconha, além de dinheiro e balança de precisão. Na sua residência, atualmente, moram seus filhos Gabriel, Guilherme e Lara. Não soube dizer a quem pertenciam as drogas, que foram encontradas no quarto de seu filho Guilherme. Somente viu as drogas no dia dos fatos, quando os policiais as encontraram e a chamaram. Disse que a balança de precisão foi encontrada na cozinha. Afirmou que as embalagens plásticas também foram encontradas na sua casa, no quarto de seu filho Gabriel. Informou que Gabriel trabalhava como motoboy quase todas as noites. Questionada sobre as declarações prestadas à autoridade policial, às fls. 09, ocasião em que afirmou que as drogas pertenciam ao réu, alegou que nada falou. Não ficou sabendo sobre o encontro de drogas na cozinha da sua casa. Disse que não autorizou o ingresso dos policiais no imóvel.

A testemunha e policial militar Aparecida Fátima Paulino Boto disse que, por ocasião do ocorrido, estava de plantão, quando houve solicitação, via Copom, sobre a denúncia da chegada de uma carga de drogas no local dos fatos. Realizou patrulhamento no local, onde a senhora Silvia, mãe de Gabriel, autorizou sua entrada na residência. Na porta da cozinha, localizou uma balança de precisão. Em cima de uma pedra de mármore, havia uma quantidade de maconha cortada para ser embalada nos plásticos que estavam ao lado. Indagada sobre outros produtos ilícitos que pudessem ter dentro da residência, Silvia a encaminhou até o cômodo onde havia pouco mais de R\$ 3.000,00, em notas diversas, ou seja, de 10, 20 e 50 reais, além de pinos de cocaína e pedras de crack, todos prontos para comercialização. Novamente indagada, Silvia confirmou que as drogas pertenciam ao seu filho Gabriel, conhecido nos meios policiais pela prática da comercialização de drogas. Disse que o réu se evadiu pelos fundos da residência, não sendo possível sua localização. Informou que, após receber a denúncia, que informava somente o endereço do imóvel, deslocou-se ao local e, logo que adentrou na rua, reconheceu a residência do réu, que já era conhecido como ponto de tráfico de drogas. Afirmou que foi a mãe do réu quem lhe franqueou a entrada na residência e a acompanhou durante toda a diligência. Destacou que Silvia confirmou que as drogas eram do réu. Esclareceu que as drogas encontradas na cozinha estavam dispostas como se tivessem sido abandonadas com a sua chegada no local. Quando perguntou à genitora do réu sobre a existência de outras substâncias no local, ela própria a encaminhou até o quarto de Gabriel e pegou o restante das drogas e o dinheiro que ali estavam, entregando-lhe em seguida. Na oportunidade, Silvia afirmou que o quarto era do seu filho Gabriel.

O policial militar Fernando Alevi Claro corroborou integralmente o depoimento de sua colega de farda. Disse que recebeu denúncia informando que, naquele momento, na rua José Pelizer, havia chegado uma grande quantidade de droga, que estaria sendo "picada" para ser comercializada. O local era conhecido como ponto de tráfico e Gabriel era conhecido por ali residir. Diante da notícia, deslocou-se ao endereço informado, onde a genitora do réu, Silvia, que se encontrava na frente da residência, franqueou-lhes a entrada no imóvel. Ao entrar juntamente com ela, ouviu um barulho no fundo, ocasião em que percebeu que Gabriel estava se evadindo pelo quintal. Acionou apoio para localizar o réu, mas não foi possível. Logo na cozinha, avistou um pedaço de maconha, que estava sendo picotado, além de uma balança de precisão. Indagada se havia mais droga ou algo ilícito no local, de pronto, Silvia o levou até um quarto, onde, no interior de uma cômoda, havia mais de R\$ 3.000,00 em dinheiro. Em seguida, a genitora entregou um pacote pequeno de cocaína e outro de crack. Destacou que não foi preciso mexer em nada no local, já que Silvia lhe

entregou tudo. Na ocasião, como não conseguiu localizar o réu, por ser ela proprietária da casa e franqueado a entrada, conduziram-na até a Delegacia de Polícia.

A testemunha de defesa Roselei Rosa disse que é vizinha do réu desde 2007, mas não é sua amiga, nem frequenta sua residência. Não presenciou o encontro das drogas e não tinha conhecimento de nenhum envolvimento de Gabriel com tráfico de drogas. Não presenciou a chegada dos policiais no local. Informou que havia policiais no interior da residência e uma policial feminina na frente da casa, conversando com a avó do réu, explicando o motivo de estarem ali, sobre a denúncia de agressão a um idoso, sendo, todavia, a avó, a única idosa no local. Viu quando os policiais saíram do interior da residência, mas não viu se estavam com drogas. Silvia não estava na frente do imóvel, motivo pelo qual acredita que ela estava acompanhando os policiais.

A testemunha de defesa Osvaldo Leonor de Lima disse que conhece o réu, que é seu vizinho. Negou possuir algum grau de parentesco ou amizade íntima com ele. Não presenciou o encontro de drogas na residência. Por ocasião do ocorrido, estava sentado na frente da sua casa, do outro lado da rua, quando os policiais lá chegaram e disseram que havia uma denúncia de maus tratos a um idoso. Entretanto, lá havia apenas uma idosa, senhora Elidia, avó de Gabriel. Não sabe quem autorizou a entrada dos policiais e não tem conhecimento se o réu possuía envolvimento com tráfico de drogas. Não ouviu, em nenhum momento, os policiais dizendo que era denúncia de tráfico de drogas. Conhece o réu desde quando ele era criança e tem conhecimento de que ele trabalhava como motoboy para sua cunhada. Afirmou que sua residência fica na mesma calçada que a de Gabriel, já que, em frente, há um campo de futebol, uma quadra e várias mangueiras. Disse que é aposentado e estava sentado embaixo de uma árvore, como de costume, onde havia um banco. Informou que a rua era bem movimentada.

A testemunha de defesa Franciele Pinheiro Barreiro disse ser irmã do réu e residir na sua companhia. Todavia, no dia dos fatos, estava na casa de seu namorado. Após receber uma ligação de sua mãe, chegou ao local e soube que sua irmã Mariele havia autorizado a entrada dos policiais na residência. Sua avó, que estava do lado de fora, disse que os policiais lá estavam para apurar uma denúncia de maus tratos a um idoso. Negou que a denúncia de agressão seria com relação à sua avó. Todavia, era ela a única idosa no local. Disse que o réu não possui envolvimento com tráfico de drogas e, atualmente, conta com 24 anos de idade. Quando menor de idade, Gabriel respondeu a processos pela Vara da Infância e Juventude, mas não se recorda quantos. Afirmou que seu irmão Guilherme não possuía problemas com drogas e não respondeu a nenhum processo criminal, nem quando menor de idade. Esclareceu que, atualmente, o réu não trabalha, mas, por ocasião dos fatos, era motoboy e trabalhava informalmente todos os dias. Ao final da audiência, ao lhe ser exibida a imagem do Google Maps, que mostra a rua da casa de Gabriel, indicou onde se localizavam as residências da testemunha Osvaldo e de sua mãe.

Interrogado, Gabriel Fernando Pinheiro Barreiro disse que, por ocasião dos fatos, trabalhava como motoboy. Declarou fazer uso de maconha desde os 16 anos. Afirmou que não estava na residência quando os policiais lá estiveram, negando ter fugido pelos fundos no momento da chegada dos agentes. Disse que respondeu a dois procedimentos pela Vara da Infância e Juventude, sendo um deles por tráfico e outro em razão de uma moto. Negou que houvesse drogas no interior da sua residência, no quarto de seu irmão Guilherme. Na época, dormia no quarto de sua avó. No imóvel, moravam seu irmão, suas irmãs e sua mãe. Conhecia os policiais Fátima e Claro, mas nada tinha contra eles e não sabe se eles possuíam algo contra si. Acredita que, por ter praticado os atos infracionais quando menor de idade, os policiais queriam pegá-lo de alguma forma, já que, na época, não daria nada e, quando maior, "iria conhecer a cadeia". Acredita que os policiais tenham dito para sua mãe que iriam averiguar o quintal e, por isso, ela os acompanhou. Disse que o valor de R\$

3.000,00 encontrado na sua residência era fruto da venda de um veículo Gol quadrado, que estava recebendo em parcelas quinzenais. Tal veículo havia sido comprado anteriormente de um amigo, por R\$ 4.500,00. Então, vendeu-o para outro amigo, que lhe entregou um valor de entrada e pagava R\$ 500,00, quinzenalmente, que guardava no guarda roupa existente no quarto onde seu irmão Guilherme dormia. Negou que as drogas lhe pertencessem ou a Guilherme.

Como se vê, as provas aqui produzidas, sob o crivo do contraditório, demonstram que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, tal como descrito na exordial.

A frágil versão apresentada não veio acompanhada de nenhum elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Os depoimentos desses agentes foram sempre seguros e harmônicos ao descreverem a dinâmica da diligência realizada na residência do réu, onde havia considerável quantidade de maconha e cocaína, na sua forma original e na forma de crack, além de dinheiro e objetos usados para embalo das substâncias, tudo após delação anônima específica nesse sentido.

Os agentes ainda relataram que, logo que ingressaram no imóvel, depararam-se com porções de maconha cortadas sobre uma pedra de mármore, prontas para serem embaladas nos plásticos que estavam ao lado, ocasião em que Gabriel não mais se encontrava no local. Destacaram que a testemunha Silvia, genitora do réu, franqueou-lhes a entrada na casa e os acompanhou durante toda a diligência, levando-os até o quarto do acusado e lá pegando o restante das drogas e a quantia em dinheiro que ele mantinha em depósito.

Ao contrário do que alega a defesa, o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência nesse sentido:

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário”. (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

“(...) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada.” (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Já a testemunha Silvia alterou substancialmente a versão apresentada na fase policial (fls. 09), ocasião em que afirmou que as drogas, o dinheiro e os objetos apreendidos pertenciam ao réu, e que nunca o denunciou por ser seu filho e por não ter coragem de entregá-lo.

Todavia, suas declarações judiciais estão dissociadas dos demais elementos probatórios coligidos aos autos, não sendo aptas a afastar a responsabilidade criminal do acusado.

As demais testemunhas não presenciaram o encontro das drogas e nada esclareceram de relevante sobre os fatos, limitando-se a reiterar a versão da testemunha Silvia, no sentido de que os policiais justificaram a presença no local com base em denúncia de maus tratos a idoso.

Há que se registrar que são elas vizinhas e irmã do réu e, portanto, ainda que indiretamente, possuem algum interesse no deslinde da ação penal.

Por outro lado, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal. Na espécie, Gabriel infringiu a norma descrita no artigo 33 da Lei de Tóxicos por guardar e ter em depósito entorpecentes, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova.

Na espécie, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, o dinheiro sem origem lícita demonstrada, os objetos comumente utilizados para armazenamento de entorpecentes, os consistentes depoimentos dos policiais militares e a denúncia anônima por ele recebidas, dão a necessária certeza de que as substâncias se destinavam ao tráfico ilícito.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime descrito na denúncia.

Caracterizadas a autoria e materialidade delitivas, a procedência integral da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo à fixação da reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que a quantidade, natureza e variedade de droga que o réu mantinha em depósito (30 microtubos de cocaína; 157 pedras de crack e 270g de maconha) são circunstâncias que, a teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, nesta primeira fase, diante da reprovabilidade de sua conduta, autorizam a exasperação da pena, de modo que a fixo em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira e derradeira fase, não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (30 microtubos de cocaína; 157 pedras de crack e 270g de maconha), juntamente com dinheiro (R\$ 3.191,00) e objetos usados para preparar e embalar drogas (balança de precisão e pequenas embalagens plásticas) jamais seriam guardados por alguém que estivesse iniciando suas atividades no tráfico de drogas, revelando, assim, que o réu se dedica ao comércio espúrio, não fazendo jus ao benefício idealizado apenas para traficantes de pequena monta.

Nesse sentido, o C. STJ já se pronunciou:

“(...) 3. Esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias em que cometido o tráfico, podem evidenciar a dedicação a

atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante. 4. In casu, a utilização da quantidade da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Verifica-se que o Tribunal a quo negou o benefício, concluindo que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa do tráfico, diante da quantidade da droga apreendida e circunstâncias do fato, de maneira que entender diversamente, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte."(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1672657/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020). Grifei

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a pena acima definitiva.

O réu cumprirá a pena inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33 § 3º, do Código Penal, c.c. o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e por compatível com a gravidade do crime praticado.

Não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR GABRIEL FERNANDO PINHEIRO BARREIRO, R.G. nº 53.912.375/SP, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Deixo de decretar a prisão do réu, por ausentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, e por ter respondido ao presente feito em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e seus parágrafos da Lei de Tóxicos, declaro o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 12/13) em favor da União, expedindo-se o necessário para tanto.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P. I. C.

Itapira, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA